

1016123-70.2021.8.26.0309

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Energia Elétrica

Magistrado: Gustavo Pisarewski Moisés

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

Foro de Jundiaí

Vara da Fazenda Pública

Senador Fonseca 957, Jundiaí - SP - cep 13201-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1016123-70.2021.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016123-70.2021.8.26.0309

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Energia Elétrica

Impetrante:

Antonelli Supermercado Ltda

Impetrado:

Delegado Regional Tributário Em Jundiaí Drt 16

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Pisarewski Moisés

Vistos.

Trata-se de ação mandamental ajuizada por ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA em face do Sr. DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO EM JUNDIAÍ.

Pretende a parte impetrante, em suma, a concessão de medida liminar, 'assegurando-se à impetrante o direito à compensação tributária por meio de creditamento do ICMS i) na escrituração fiscal ou ii) nas próprias faturas vincendas de energia elétrica. Subsidiariamente, requer-se o deferimento de medida liminar suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário em debate (art. 151, inc. IV, do CTN)' (sic).

Ao final, pretende a procedência da ação, com a concessão definitiva da segurança, 'assegurando-se o direito líquido e certo da impetrante: a) de não mais ser compelida ao recolhimento do ICMS sobre a aludida demanda contratada, mas, apenas e tão somente sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida; b) de efetuar

a compensação do indébito tributário, a ser oportunamente efetivado, alternativamente, por meio de creditamento do ICMS i) na escrituração fiscal ou ii) nas próprias faturas vincendas de energia elétrica, observando-se: b.1) o prazo prescricional quinquenal; b.2) incidência de taxa SELIC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, ou, subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela autoridade impetrada quando da cobrança de seus créditos. c) determinando-se que a autoridade impetrada se abstenha de obstar o exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio - administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes ao imposto em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle' (sic).

Inicial a fls. 01/17, documentos a fls. 18/84.

O pedido liminar foi deferido em parte, fls. 85/94, para, com fundamento no artigo 151, IV, CTN, decretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica contratada e não utilizada, incidindo ICMS apenas sobre a operação de fornecimento de energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento da parte impetrante.

Contra a decisão que deferiu em parte o pedido liminar, o impetrante interpôs embargos declaratórios a fls. 101/104, que foram rejeitados a fls. 105.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo ingressou no feito a fls. 108 como assistente litisconsorcial.

O impetrado prestou informações a fls. 139/153.

A douta Promotoria de Justiça se manifestou ao final, fls. 158.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

De rigor o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada.

Em especial, não há se falar em ilegitimidade ativa do impetrante.

Com efeito, apesar da parte impetrante não ser o contribuinte de direito, mas sim o de fato, tem ela legitimidade para discutir em juízo a exação em questão.

Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA 'CONTRATADA E NÃO UTILIZADA'. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. - O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de

energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil" - Recurso Especial n. 1299303/SC, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 08.08.2012, grifo nosso.

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE FATO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No tocante à legitimidade ativa, de acordo com a atual orientação desta Corte, fixada no julgamento do REsp 903.394/AL, sob o regime dos recursos repetitivos, somente o contribuinte de direito tem legitimidade ativa para a demanda relacionada aos tributos indiretos, ou seja, aqueles em que o ônus tributário, pela própria natureza e sistemática da exação, repercute-se no patrimônio do contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do CTN (REsp 928875/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 01/07/2010). 2. No entanto, em relação à legitimidade ativa especificamente do consumidor de energia elétrica, a Primeira Seção desta Corte, em recurso julgado também sob a sistemática do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que, diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade processual para questionar a incidência do ICMS sobre a energia elétrica, com fundamento no art. 7º, II, da Lei 8.987/95, não obstante as disposições do art. 166 do CTN, que veiculam regra geral de legitimidade apenas ao contribuinte de direito. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de se reconhecer a legitimidade do embargante para pleitear repetição/compensação de indébito" - Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1270547/RS, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Eliana Calmon, j. 04.06.2013, grifo nosso.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO. I - O acórdão embargado não apreciou as questões apresentadas no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto concluiu pela ilegitimidade ativa da Impetrante, sob o fundamento de que os consumidores de energia elétrica não possuem legitimidade ativa para pleitear a repetição de eventual indébito tributário do ICMS incidente sobre essas operações. II - O consumidor possui legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. III - Embargos de Declaração acolhidos com excepcionais efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos para nova análise do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança" - Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 33.838/CE, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Regina Helena Costa, j. 15.12.2015, grifo nosso.

Outrossim, não há se falar em suspensão do curso do processo, à medida que a matéria aqui discutida não foi afetada, quer pelo IRDR n. 2246948-26.2016.8.26.0000, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quer pelo Tema de Recurso Repetitivo n. 986 (Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1163020/RS), do E. Superior Tribunal de Justiça.

O mais toca ao mérito da lide, até por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

No mérito, a ação é parcialmente procedente, com a concessão parcial do writ.

É firme o entendimento jurisprudencial, já pacífico, de que não há lastro jurídico na incidência de ICMS sobre energia elétrica contratada e não utilizada, pois ausente a ocorrência do fato gerador do imposto, que é a efetiva (e não ficta)

circulação econômica de mercadoria.

A questão já foi inclusive resolvida em sede de precedentes vinculantes, artigo 927, NCPC, confira-se:

"É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada" – Tema de Recurso Repetitivo n. 63 do E. Superior Tribunal de Justiça, afetado ao Recurso Especial n. 960476/SC, 1ª Seção, m. v., relator Ministro Teori Zavascki, j. 11.03.2009.

"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" – Tema de Repercussão Geral n. 176 do Col. Supremo Tribunal Federal, afetado ao Recurso Extraordinário n. 593824/SC, Pleno, m. v., relator Ministro Edson Fachin, j. 19.05.2020.

Nesse mesmo sentido:

"O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" (Súmula n. 391 do E. Superior Tribunal de Justiça).

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa". 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08" – Recurso Especial n. 960.476/SC, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2009.

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA MAS NÃO UTILIZADA. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado

pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 960.476/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido" - Agravo Interno no Recurso Especial n. 1430460/GO, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Regina Helena Costa, j. 23.08.2016.

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A Corte Estadual não se manifestou sobre as alegações de impossibilidade do pedido de compensação, inadequação da via eleita e prescrição das parcelas anteriores a abril de 2004, tampouco essas questões foram objeto dos embargos declaratórios opostos. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 3. A Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 960.476/SC, consolidou a compreensão de que "É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada" (Tema 63 dos Recursos Repetitivos). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" - Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1325024/GO, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Sérgio Kukina, j. 09.08.2016.

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. ART. 543-B DO CPC. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FATO GERADOR DO ICMS RELATIVO À ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA E NÃO A MERA DEMANDA CONTRATADA OU RESERVADA DE POTÊNCIA. SÚMULA 391 DO STJ E RESP 960.476/SC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar pendente de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão geral, não obsta o julgamento, nesta Corte, do Recurso Especial. O exame de eventual necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.411.517/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 367.302/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014. II. Estabelece a Súmula 391/STJ que "o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada". III. Na esteira da diretriz firmada na Súmula 391/STJ, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 960.476/SC, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que o fato gerador do ICMS, no caso de fornecimento de energia elétrica, é a energia efetivamente consumida. Entendeu-se, assim, que deveria ser excluída, da base de cálculo do ICMS, a demanda de potência contratada ou reservada e não utilizada. IV. Não há de se cogitar de jurisprudência oscilante, quando os supostos precedentes, em sentido contrário, ou não se aplicam ao caso dos autos, ou se encontram já superados pelo entendimento atual desta Corte. V. Agravo Regimental improvido" - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 554.115/CE, 2ª

Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministra Assusete Magalhães, j. 27.10.2015.

É o que basta para a concessão do mandamus, ainda que em parte.

Por fim, reconhecida a inexigibilidade tributária, de rigor reconhecer o direito de repetição indébito quanto aos valores pagos a tal título (artigo 165, CTN), observada a prescrição quinquenal (artigo 168, CTN), o que, porém, deve ser buscado em ação própria, descabendo para tal fim a ação mandamental (Súmulas ns. 269 e 271, ambas do Col. Supremo Tribunal Federal).

De outra banda, não se nega que a ação mandamental é meio processual adequado para o reconhecimento, em abstrato, do direito à compensação tributária (Súmula n. 213 do E. Superior Tribunal de Justiça; e Tema de Recurso Repetitivo n. 118, também do E. Superior Tribunal de Justiça).

Ocorre que esse entendimento de direito está restrito ao aspecto meramente processual, insuficiente por si só para a concessão da ordem, à medida que, além disso, é necessário o aspecto material, ou seja, o direito em si de compensação tributária.

Em outros termos, só essa questão de ordem processual não traz automaticamente e imediatamente o direito material em si de o contribuinte obter judicialmente qualquer compensação de crédito tributário.

E, aqui, na espécie dos autos, o contribuinte, ora impetrante, não tem direito material algum de compensação desse crédito por escrituração contábil, à medida que ausente permissivo legal próprio e específico para a espécie em exame.

E sem lei estadual permitindo a compensação para a hipótese dos autos, inviável o reconhecimento de tal direito, que, assim, fica indeferido, negada a ordem nesse ponto.

A respeito:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Nos termos da firme jurisprudência deste STJ, não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. Precedentes: AgRg no AREsp 60.599/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/04/2015 e AgRg no REsp 1285053/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/03/2012. 2. Ausente a lei específica do Estado do Espírito Santo regulamentando a compensação, subsiste o pedido da parte impetrante de restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos dez anos. No entanto, o manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Agravo interno de Tim Celular S/A a que se nega provimento” – Agravo Interno no Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 42.719/ES, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Sérgio Kukina, j. 27.10.2016.

Por conseguinte, inaplicável também ao caso o entendimento da Súmula n. 461 do E. Superior Tribunal de Justiça.

A compensação tributária demanda prévia e expressa permissão legal (artigo 170, CTN), o que não há na espécie.

Com efeito, não há norma legal algum autorizando ou disciplinando o direito à compensação tributária em casos que tais, o qual, por sua vez, não se confunde em nada com o direito à não-cumulatividade do ICMS.

Deveras, nem a Lei Estadual n. 6.374/1989, nem o Decreto Estadual n. 45.490/2000 (RICMS) dispõem ou disciplinam a hipótese de compensação de crédito de ICMS em favor do contribuinte de fato (que é o caso do impetrante na espécie) e originado de pagamentos feitos anteriormente a maior para terceiros (que são os contribuintes de direito nessa operação).

Aliás, a mera circunstância de ser aqui o impetrante contribuinte de fato afasta, a seu favor, qualquer direito de compensação tributária, à míngua de regra legal própria e específica, que não há, e afasta o cabimento de ser tal compensação fundada no princípio da não-cumulatividade desse imposto.

E, ademais, a mera circunstância de o contribuinte de fato na tributação em discussão, a quem no caso é devida a repetição do indébito, ser também, em outras operações, contribuinte de direito do ICMS, não lhe confere a prerrogativa, exatamente por falta de previsão legal própria e específica, de proceder a qualquer compensação tributária, devendo se submeter, como os demais contribuintes de fato, em total situação de isonomia, à via regular da repetição por ação própria, através de oportuno e regular requisitório.

Nesse sentido, e a título de razões de decidir:

“Apelação Cível. Demanda declaratória c/c repetição de indébito. ICMS. Pretensão ao reconhecimento de não-incidência sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD), encargos de conexão e encargos emergenciais, com restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 10 anos. Improcedência. Inconformismo. Cabimento em parte. ICMS que tem por fato gerador a circulação jurídica da mercadoria energia elétrica, perfectibilizada quando do efetivo consumo do bem, momento que não se consolida na fase de transmissão e distribuição elétrica, meras etapas do fornecimento Transmissão e distribuição que, ademais, equivalem a fases de transporte da energia elétrica, sem mudança de titularidade do bem. Incidência do enunciado da Súmula nº 166 do A. STJ. Não-incidência do tributo. Jurisprudência copiosa da Corte Especial. Repetição de indébito. Prescrição. Perecimento quinquenal da pretensão à restituição do imposto indevidamente pago. Prazo decenal, assentado na jurisprudência do A. STJ na denominada “tese dos cinco mais cinco”, que somente era aplicável às demandas ajuizadas antes de decorrido o prazo de *vacatio legis* da Lei Complementar Federal nº 118/2005. Precedente do E. STF em repercussão geral. (...) Compensação. Inviabilidade. Dependência de lei regulamentadora, cuja ausência constitui óbice intransponível Inteligência do art. 170 do CTN. Jurisprudência desta C. Câmara e E. Tribunal. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido. (...)

Finalmente, cumpre analisar o pedido dos demandantes no sentido de que seja permitida a compensação entre os valores a serem restituídos e débitos futuros de ICMS, sem devolução em pecúnia.

Neste ponto, porém, a pretensão não comporta guarida.

Com efeito, consabido que a compensação, em matéria tributária, nos termos do art. 170 do CTN, depende de lei específica que regule suas condições e garantias, não bastando à sua autorização a mera existência concomitante de dívidas e créditos recíprocos entre Fisco e contribuinte, diferindo, portanto, do instituto previsto no art. 368 do CC.

Ocorre que inexiste no Estado de São Paulo, quanto ao ICMS, lei permissiva de compensação entre créditos e débitos do imposto, o que, de per si, desautoriza a sua realização.

Vale destacar que os comandos legais invocados pelos requerentes a fim de fundamentar o pedido de compensação, contrariamente ao por eles defendido, não

autorizam tal modalidade de extinção de obrigações.

Realmente, o art. 63 e incisos do RICMS/2000 (Decreto Estadual nº 45.490/2000), assim como a Portaria CAT nº 83/91, não tratam da possibilidade de compensação entre créditos decorrentes da cobrança indevida do ICMS, senão disciplinam a possibilidade de aproveitamento de créditos escriturais.

Ora, sabido que, a fim de operacionalizar comercialmente o princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS, segundo o qual se deve compensar o tributo devido em determinada operação de saída com o montante pago a este título nos negócios pretéritos, cabe ao contribuinte proceder à escrituração contábil de seus créditos de imposto, decorrentes da entrada de mercadorias no estabelecimento, e seus débitos, devidos na saída.

No entanto, esses créditos, a serem abatidos dos débitos de ICMS em cálculo que levará ao valor do imposto devido pelo contribuinte em determinado período de apuração, não representam um direito a receber prestação pecuniária do Estado. Traduzem-se, como visto, em ativos escriturais, oponíveis apenas para abatimento do total de ICMS devido pelo contribuinte em operações de saída.

Já os valores a serem repetidos aos requerentes, ora reconhecidos, constituem créditos na acepção pura do termo, representando direito a recebimento de valores, não estando, por isto, abarcados na legislação invocada pelos requerentes, que trata da compensação tão-apenas como consequência da não-cumulatividade.

Portanto, não há mesmo legislação estadual a autorizar a compensação pretendida, o que impede seu deferimento, por óbice do art. 170 do CTN. Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara em caso análogo, solução perfilada também pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

ICMS - Energia Elétrica - Repetição de indébito - Legitimidade ativa do contribuinte de fato - Recolhimento do imposto comprovado por meio de notas fiscais - Aplicação do prazo prescricional decenal - Contrato de demanda - Incidência do imposto sobre a demanda reservada - Inadmissibilidade O imposto estadual deve incidir sobre a energia efetivamente consumida - Compensação não prevista em lei - Correta a aplicação de juros de mora desde o recolhimento indevido, aos índices da Taxa SELIC - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada nesta parte Recurso da autora provido em parte, desprovido os remanescentes. (TJSP, Ap. Cív. nº 681.767-5/5-00, Rel. Des. PEIRETTI DE GODOY, 13ª Câmara de Dir. Púb., j. 18.2.2009 o grifo o foi por nós)

Apelação Mandado de segurança preventivo - ICMS - Contrato de demanda de energia elétrica - Imposto devido somente sobre a energia efetivamente consumida - Inteligência dos artigos 155, II e § 3º, da CF, 116, II, do CTN e 19 do Convênio 66/88 - Incidência do enunciado da Súmula nº 391 do STJ - Impossibilidade de compensação do ICMS pago sobre a energia elétrica contratada com créditos tributários por ausência de legislação específica - Inteligência do artigo 170 do CTN - Cobrança de TUST e TUSD - Ausência de comprovação de direito líquido e certo - Declaração de inexigibilidade do ICMS sobre o Encargo de Capacidade Emergencial ("Seguro-Apagão") - Decadência - Inteligência do artigo 18 da Lei nº 1.533/51 - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte. (TJSP, Ap. Cív. nº 0019323-28.2009.8.26.0114, Rel. Des. PAULO BARCELLOS GATTI, 4ª Câmara de Dir. Púb., j. 30.9.2013 o grifo o foi por nós)

(...) - Apelação nº 0131153-56.2007.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Souza Meirelles, j. 15.10.2014, grifos e destaques do original.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação e concedo em parte a segurança, para, rejeitado o mais requerido na inicial, tornar definitiva a medida liminar antes deferida e decretar a inexigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica contratada e não utilizada, incidindo ICMS apenas sobre a operação de fornecimento de energia elétrica efetivamente consumida.

O impetrado deverá adotar as medidas e providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem, sob as penas da lei, restrita, por óbvio, à sua área

territorial de atuação funcional.

Custas na forma da lei.

Sem condenação em honorária, descabida na espécie (Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de Justiça; Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal; e artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/2009).

Oportunamente, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei Federal n. 12.016/2009, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, com nossas homenagens, na forma da lei e com as cautelas de praxe, independentemente de recurso voluntário, para sua sábia e douta apreciação recursal em sede de reexame necessário.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I.

Jundiaí, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA